

민법 제150조의 적용대상 및 인과관계 문제에 관한 짧은 고찰*

임 현 정**

〈요 약〉

민법 제150조는 과거에는 잘 활용되지 않았으나 최근에 그 적용을 주장하는 실무자와 법학자들이 많아지고 있는 조문이다. 그럼에도 이에 대한 민법학자들에 의한 연구는 부족한 상태여서 필자는 이 조문에 대해 연구해 볼 필요성이 있다고 생각한다.

현재 민법 제150조에 대한 대법원 판례를 검토하여 본 결과, 우리 대법원은, 단지 ‘조건부 권리’이기만 하면 본조의 적용대상이 되는 것이 아니라 조건부 권리의 성숙성(가능성)을 기준으로 제150조에 의한 보호여부를 결정하는 태도를 보이고 있다. 이러한 판례의 태도는 가장 직접적으로는 일본 학설의 영향을 받은 것이었고, 그 배경에는 단순한 기대와 주관적 권리로서의 기대권을 구별하는 독일학자들의 기대권에 관한 논의가 영향을 미쳤다는 결론을 내릴 수 있다. 그러나 필자는 이렇게 본조의 적용대상을 구분하는 판례의 태도가 적절한지에 대해서는 의문을 가지고 있다.

그리고 민법 제150조의 요건 중 ‘인과관계’에 대해서는, 조건부 권리가 가지는 ‘불확실성’이라는 태생적 특수성으로 인해, ‘방해행위가 없었다면 조건이 성취되었을 것인가’라는 가정적 인과관계의 증명을 전적으로 요구하거나 전적으로 요구하지 않는 현재의 학설대립은 한계점이 있다. 이에 필자는 대안적으로 기회상실이론을 차용하여 비율적인 손해배상을 할 수 있음을 제안한다.

[검색어] 민법 제150조, 조건, 조건 성취 방해, 조건부 권리, 가정적 인과관계

* 존경하는 정현미 교수님의 정년을 진심으로 축하드립니다. 교수님, 늘 건강하시고 행복하시기를 바랍니다. 이 논문은 필자의 “민법상 조건(條件)법리에 관한 연구-민법 제150조를 중심으로-”, 이화여자대학교 박사학위청구논문, 2024.를 일부 요약한 후 발전시킨 내용으로, 2024. 9. 27. 이화여자대학교 법학연구소 주최 제2회 신진학자 학술대회에서 발표한 발표문입니다. 지정토론을 통해 귀한 의견을 제시해 주신 전남대학교 법학전문대학원 권오상 교수님께 감사드리고, 심사의견을 주신 심사위원님들께도 감사드립니다.

** 대법원 재판연구관, 법학박사, 변호사

I. 들어가며

잘 알지 못하는 법률문제를 맞닥뜨렸을 때, 법률가들이 가장 먼저 펼쳐보는 자료는 바로 법전(法典)일 것이다. 해당 사안에 적용될 조문이 있지 않은지 법전을 천천히 읽어나가다가 적용이 가능할 것 같은 조문을 발견해 내는 경험은 상당한 희열을 줄 뿐만 아니라 장차 새로운 이론이나 판례를 만들어 내는 결과로 이어질 수 있다는 점에서 법률가에게 중요한 경험으로 여겨진다.

민법 제150조는 위와 같은 ‘조문의 발견’이라는 면에서 보았을 때 연구할 만한 가치가 있는 조문이다. 2014년 이전까지 민법 제150조가 직접 적용된 대법원 판례는 2건에 불과했으나, 2015년 이후 본조를 주장하는 사건이 증가하고 있어¹⁾ 이른바 ‘떠오르는 조문’이라고 할 수 있기 때문이다. 그러나 민법 제150조에 대한 민법학자들의 연구는 많지 않은 편이어서²⁾ 법률실무자인 변호사나 법관들조차도 위 조문에 대해 상반된 해석을 내놓는 경우가 있다.

이에 본고에서는 판례가 민법 제150조에 대해 어떠한 태도를 가지고 있는지 살펴보면서 판례태도에 제기될 수 있는 의문을 살펴본 후, 본조의 운용에서 발생할 수 있는 문제점을 해결하기 위한 대안적 방안을 모색해 보고자 한다.

우리 민법 제150조는 다음과 같이 규정하고 있다.

제150조(조건성취, 불성취에 대한 반신의행위)

- ① 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에는 상대방은 그 조건이 성취한 것으로 주장할 수 있다.
- ② 조건의 성취로 인하여 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에는 상대방은 그 조건이 성취하지 아니한 것으로 주장할 수 있다.

1) 법제처 국가법령정보센터 검색결과 2024. 9. 9. 까지 민법 제150조가 직접 적용된 대법원 판례는 총 11건.

(<https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060114#undefined>)참조(최종 방문일 2024. 9. 9.)

2) 양창수, “민법 제150조의 입법목적과 유추적용”, 『사법』(사법발전재단, 2020), 제1권 제51호; 윤진수, “정지조건 성취 방해로 인한 조건성취의 의제여부-대법원 2021. 1. 14. 선고 2019다223054판결-”, 『민사법학』(한국민사법학회, 2021), 제96권; 권오상, “민법 제150조 제1항의 조건 성취에 대한 반신의행위 검토 — 대법원 2022. 12. 29. 선고 2022다266645 판결 —”, 『법학연구』(연세대학교 법학연구원, 2023), 제33권 제1호.

이 조문을 읽었다면 이제는 아래 세 가지 사례를 읽어보고 민법 제150조 제1항을 주장할 수 있는 사안인지 생각해 보자.

사례 1.³⁾

의뢰인 B는 甲사건의 제1심에서 패소한 후, 변호사 A와의 사이에 항소심 사건을 위임하면서 다음과 같은 성공보수 약정을 하였다.

“甲사건에서 승소하면 의뢰인 B는 변호사 A에게 승소금액의 1/3을 지급한다.”

그런데 항소심 진행도중 의뢰인 B는 승소할 가능성이 없다고 판단하여 변호사 A와 상의하지 않고 항소를 취하하였다. 변호사 A는 민법 제150조 제1항을 근거로 의뢰인 B를 상대로 성공보수금을 청구할 수 있을까?

사례 2.

B는 A에게 “내가 올해 서울시 공무원 7급 공채시험에 합격한다면 1천만 원을 주겠다.”라고 약속했다. 그런데 시험이 실시되기 얼마 전 B는 A가 열심히 공부하는 것을 보고 정말로 A에게 1천만 원을 주어야 할 수도 있다는 생각에 돈이 아까운 마음이 들었다. 그래서 A가 평소 일어나는 시간에 A의 알람시계를 끄고 집 밖으로 나가버렸다. 제 시간에 일어나지 못한 A는 공무원 시험에 응시하지 못하였고, 결국 불합격하였다. A는 민법 제150조 제1항을 근거로 B에게 1천만 원을 청구할 수 있을까?

사례 3.⁴⁾

X임야를 보유하고 있던 A는 공인중개사 B와의 사이에 “X토지의 매매계약이 성사되면 토지가액의 3%에 해당하는 금액을 중개보수로 지급한다.”라고 약정하였다. 공인중개사 B는 임야매입을 원하던 C를 알게 되어 A와의 사이에 매매대금 등 거래조건을 교섭하여 3천만 원에서 대금이 결정되었으나 A는 이 매매가액을 거절하였다. 이후, A는 중개보수를 지급하기 아까운 마음이 들어 B와의 약정을 해제하고 C에게 직접 연락하여 매매대금 등을 합의 한 결과 3천 100만원으로 결정되었고, 이 가격으로 C와의 사이에 X임야에 대한 매매계약을 체결하였다. 공인중개사 B는 민법 제150조 제1항을 근거로 약정한 중개보수 전액(3% 상당)을 A로부터 지급 받을 수 있을까?

위 사례들은 공통적으로, 장래에 발생할지 모르는 불확실한 사실(승소, 합격, 매매계약 체결)이 발생하게 되면 권리자가 권리를 취득하는 방식을 취하고 있는 약정들이다. 조건(條件)이란, 법률행위의 효력의 발생 또는 소멸을 장래의 불확실한 사실의 성부 또는 성

3) 대법원 1979. 6. 26. 선고 77다2091 판결의 사실관계를 각색한 것이다.

4) 最高裁 1970. 10. 22. 昭和45(オ)637(民集 24-11, 1599) 판결의 사실관계를 각색한 것이다. 해당 판결은 이 사건을 일본민법 제130조(우리 민법 제150조)에 해당하는 문제로 판단하고 있다.

취에 의존하게 하는 법률행위의 부관⁵⁾을 말하므로, 위 사례에서와 같은 약정을 우리는 ‘조건부 약정’이라고 부르고, 그 약정에 기해 장차 권리를 취득하게 될 사람은 ‘조건부 권리’를 보유한다고 한다.

위 사례 1.에서 변호사 A는 민법 제150조 제1항을 읽어 본 후, ‘승소’라는 조건사실이 발생하면 의뢰인 B는 변호사 A에게 성공보수금을 지급하여야 하므로 조건의 성취로 인하여 불이익을 받게 될 당사자에 해당하고 변호사 A는 그 상대방에 해당하므로 의뢰인 B가 성공보수금을 지급하지 않기 위해 소를 취하하였다면 이는 민법 제150조 제1항에서 정하는 ‘조건 성취 방해’행위에 해당하므로 변호사 A는 의뢰인 B에게 성공보수금을 청구할 수 있다고 생각하였다. 이에 변호사 A가 민법 제150조 제1항에 근거해 의뢰인 B에게 성공보수금을 청구하자 의뢰인 B는 “어차피 甲사건은 승소할 가능성이 전혀 없는 사건이었다. 따라서 나는 성공보수금을 지급할 수 없다.”라고 주장하였다. 이러한 주장은 타당한가?

위 사례 2.에서 A 또한 B에게, B가 조건의 성취를 방해한 것이므로 민법 제150조 제1항의 효과로서 1천만 원을 지급해 달라고 하였다. 그러자 B는 “A는 학창시절 학업성적이 낮은 학생이었으므로 이번 공무원 시험에 합격할 확률이 낮았다. 내가 알람시계를 끄는 행위를 하지 않았더라도 A는 시험에 불합격 했을 것이므로 나는 약정한 1천만 원을 지급할 수 없다.”라고 주장했다. 이러한 주장은 타당한가?

또한 위 사례 3.에서 A는 “매매계약 성립은 내가 직접 매매대금에 대한 교섭을 한 결과 이지 공인중개사 B의 행위에 따른 결과가 아니다. 따라서 약정한 중개보수 전액을 지급할 수 없다.”라고 주장하였다. 이러한 주장은 타당한가?⁶⁾

위 3개의 사례 중 우리 대법원 판례가 존재하는 사안은 사례 1. 이다.⁷⁾ 대법원은 의뢰인 B의 주장을 받아들여 甲사건은 승소가능성이 전혀 없었으므로 민법 제150조 제1항은 적용될 수 없다는 취지로 판단한 것이다. 변호사 A로써는 민법 제150조를 아무리 읽어보아도, 가능성(여기서는 승소가능성)이 높은 조건부 권리에만 본조가 적용된다는 표현은 없다고 생각하여 위 판례의 취지를 이해할 수 없었다. 이러한 판례의 태도는 어떻게 이해

5) 박윤직·김재형, 『민법총칙』(박영사, 2012), 390면; 송덕수, 『신민법강의』(박영사, 2018), 203면.

6) 이 문제를 일본민법 제150조(우리 민법 제150조와 유사한 내용)의 문제로 보는 일본판례 및 학설에 대해서는 이재웅·김영규, “중개의뢰인의 개업공인중개사 배제에 따른 중개보수청구권에 대한 고찰 -일본 판례의 분석을 중심으로-”, 『법학논총』(단국대학교 법학연구소, 2018), 제42권 제2호, 251-264면 참조.

7) 대법원 1979. 6. 26. 선고 77다2091 판결의 사실관계를 바탕으로 각색한 사례이므로 판결의 구체적인 내용과는 다르나 이해의 편의를 위해 각색한 것이다. 위 판결의 구체적인 사실관계는 뒤의 II. 1. 가. 1) 과 같다.

할 수 있는 것일까? 본고의 첫 번째 주제는 이것이다.

그리고 사례 1, 2와 같이 B가 조건사실의 불확실성(조건이 이루어지지 않을 확률)을 들어 민법 제150조 적용을 거부한다면 이러한 불확실성 문제는 어떻게 해결하는 것이 합리적일까? 이것이 본고의 두 번째 주제이다.

II. 적용대상에 관한 판례의 태도 이해

1. 조건부 권리의 성숙성(가능성)을 기준으로 제150조에 의한 보호여부를 결정하는 판례의 태도

(1) 변호사 성공보수 사건(대법원 1979. 6. 26. 선고 77다2091판결)

1) 사실관계

원고는 변호사이고 피고는 원고에게 사건을 위임하였던 의뢰인이다. 위임사건에 있어서 원고와 피고는 성공보수 약정을 하였는데, 그 내용 중에는 “甲사건에서 승소하면 의뢰인(피고)은 변호사(원고)에게 승소금액의 1/3을 지급한다. 다만, 소취하지 승소로 간주한다.”라는 조항이 있었다. 甲사건에서 피고는 제1심 패소하였고, 항소심에 들어서서 피고는 항소심에서도 패소할 것이고 항소심판결이 날 경우 소송비용만 부담하게 될 것이라 생각하여 원고와의 상의 없이 항소를 취하하였다. 그러자 원고는 위 성공보수약정 단서에서 소취하는 승소로 간주한다고 하였으므로 피고는 원고에게 성공보수를 지급해야한다고 주장한 사건이다.

2) 항소심의 판단⁸⁾

“소취하 시 승소간주의 소송위임계약상의 특약은 의뢰인의 반신의 행위를 제제하기 위한 것이므로 민법 제150조 규정에 비추어 승소의 가능성이 있는 소송을 부당하게 취하하여 변호사의 조건부 권리를 침해하는 경우에 한하여 적용되는 것이라 할 것이며 승소의 가능성 없는 소송을 취하하는 것은 소송비용 절약이나 부당 소송행위의 피지 의무상 소송 당사자인 의뢰인의 당연한 권리로서 변호인이 이에 대하여 이의를 할 수 없는 것이므로 해당 소송이 승소 가능성이 있는 것인지 여부에 관하여 살펴야 하는데, 해당소송은

8) 서울고등법원 1977. 10. 6 선고 76나2424 판결.

승소가능성이 전혀 없었으므로 피고의 소취하 행위가 원고를 배신하는 부당행위로 인정되지 아니하므로 원고의 승소간주 주장은 이유 없다.”라고 설시하며 원고의 청구를 기각하였다.

3) 대법원

“원고와 상의 없이 동 사건을 항소 취하하였으므로 소취하시 승소로 간주한다는 특약의 취지에 비추어 동 피고는 원고에게 약정사금을 지급하여야 한다는 원고의 주장에 대하여, 당사자 간에 그러한 특약이 있어도 그와 같은 특약은 의뢰인의 반신의행위를 제지하기 위한 것이므로 민법 제150조 규정에 비추어 승소의 가능성이 있는 소송을 부당하게 취하여 변호사인 원고의 조건부 권리를 침해하는 경우에 한하여 적용되는 것이라 할 것이며, 승소의 가능성이 전연없는 소송을 취하하는 경우에는 적용될 수 없다.”⁹⁾라고 하며 원고 패소판결을 하였다.

4) 검토

이 판결은 민법 제150조가 우리 대법원 실무에서 최초로 언급된 판결로 의미가 있다.¹⁰⁾ 이 판결은 비록 민법 제150조 1항의 직접 적용을 주장한 사건은 아니었으나 대법원의 판단에서 민법 제150조의 취지를 언급하고 있어 우리 대법원이 민법 제150조를 어떻게 바라보고 있는지를 참조할 수 있는 자료이다. 판결이유에서 간단히 언급되고 있으나, 이 판결에서 주목할 점은 조건이 성취될 가능성이 전혀 없는 경우에는 민법 제150조가 적용될 수 없다고 설시하여 판례는 원고가 지니는 조건부 권리가 실현될 가능성이 있는 상태여야만 한다는 숨은 요건을 요구하고 있음을 알 수 있다.

(2) 동반매도청구권 사건(대법원 2021. 1. 14. 선고 2018다223054 판결)

1) 사실관계¹¹⁾

원고는 투자목적회사로, 사모투자전문회사(제1투자자들)로부터 제1투자자들과 피고 두산인프라코어 주식회사가 체결한 ‘두산인프라코어 차이나’의 주식에 대한 주식매매계약과 동반매도요구권을 주된 내용으로 하는 두산인프라코어 차이나 주주 간 계약의 계약

9) 대법원 1979. 6. 26. 선고 77다2091 판결.

10) 양창수, 앞의 논문(주 2), 291면.

11) 대법원 2021. 1. 14. 선고 2018다223054 판결의 사실관계 부분을 정리한 것이다.

상 지위를 승계 받은 자이다.

이 사건 동반매도요구권의 내용은 다음과 같았다.

- i. 3년 내에 두산인프라코어 차이나가 상장하지 못하면 일방주주(매도주주)는 그 소유의 두산인프라코어 차이나의 주식을 매도할 수 있다. 이때 그 일방주주(매도주주)는 상대방에게 상대방 소유 주식 전부를 함께 매도할 것을 요구할 수 있다.
- ii. 상대방은 일방주주(매도주주)의 동반매도 요구권에 대하여 다음의 대응을 할 수 있다.
 - ①조건(x): 일방주주(매도주주)의 동반매도에 동의함. 이 경우 매수인은 제3자임.
 - ②조건(y): 일방주주(매도주주)가 보유한 두산인프라코어 주식회사의 주식 전부를 (매도 결정통지서에 기재된 가격) 또는 (사전에 약정한 가격)중 상대방이 선택한 가격으로 매수 함. 이 경우 매수인은 상대방임.
 - ③조건(z): 일방주주(매도주주)가 보유한 두산인프라코어 차이나의 주식 전부를 보다 유리한 조건으로 새로운 제3자에게 매도할 것을 제안함. 이 경우 매수인은 제3자임.
- iii. 다만 상대방이 일방주주(매도주주)의 매도결정통지를 수령하고도 14일 이내에 위 (x),(y),(z)의 통지를 하지 않는다면 (x)로 간주된다.

실제로 3년 내에 두산인프라코어 차이나는 상장하지 못하였고 원고는 동반매도요구권 행사를 위하여 피고 두산인프라코어에게 투자소개서 작성을 위한 여러 자료 제공을 요청하였으나, 피고 두산인프라코어는 진정성 있는 매각절차가 구체화되는 시점에 제공 여부를 검토하겠다는거나 직접 만나 그 진정성과 선의를 확인하고 싶다고 하면서 원고의 자료 제공요구에 응하지 않았다. 결국 원고가 투자소개서 작성을 준비하던 중 위 매각 절차는 중단되었다.

이에 원고는 매수 예정자와 매각금액의 결정이 동반매도요구권의 정지조건임을 전제로 민법 제150조 제1항에 따라 피고가 신의성실에 반하여 조건성취를 방해하였으므로 조건성취가 의제되어야 한다고 주장하며 피고에게 주식매매계약 체결이 의제되므로 주식의 매각대금 상당의 금액을 지급해야 한다고 주장하였다.

2) 제1심 및 항소심의 판단

제1심 법원은 “매수예정자의 결정”이 법률행위의 효력, 즉 이 사건 동반매도요구권의 효력 발생을 장래의 불확실한 사실에 의존하게 하는 조건에 해당한다고 보기 어렵다.”라고 판시하여 매수 예정자의 결정이 동반매도요구권 행사의 정지조건이 아니라고 판단하였다. 따라서 원고의 조건성취 방해주장은 성립될 수 없는 것이나 제1심 법원은 이에 대해서도 판단하면서, 피고 두산인프라코어가 매수희망자들의 선의 여부를 확인한 후에 통

상적인 M&A 수준의 자료를 제공하겠다는 입장을 취한 것을 두고 입찰절차를 통한 매수 예정자의 결정 과정을 방해한 행위로 평가할 수는 없다.¹²⁾라고 판시하였다.

반면 항소심 법원은 원고의 조건성취 방해 주장을 받아들여 주었다. 항소심은 “매수 예정자와 매수금액의 결정이 동반매도청구권의 효력을 발생시키는 정지조건에 해당”¹³⁾ 한다고 인정한 다음, “피고 두산인프라코어는 이 사건 매각절차에 협조할 의무가 있음에도 불구하고, 이러한 협조의무를 위반하여 원고의 동반매도요구권 행사의 정지조건이 되는 매수예정자와 매각대금 결정의 성취를 방해하였다고 할 것이다.”¹⁴⁾ 라고 판시하였다. 따라서 원고가 주장하는 조건성취는 의제되어 주식매매계약이 체결된 것으로 의제되어야 하므로 피고는 원고에게 주식매매대금을 지급할 의무가 있다고 판단하였다.

3) 대법원의 판단

대법원은 “원고의 동반매도요구권 행사만으로는 매도 상대방이 누구인지, 매각금액이 얼마인지 구체적으로 특정되지 않는 점, 병 회사의 선택이 있어야만 (x), (y), (z)에 따라서 매매계약의 당사자, 매매대상, 매매금액 등이 전혀 다른 별개의 매매계약의 체결이 의제되는 점, 위 매각절차가 법적 구속력이 없는 인수의향서만 제출받은 상황에서 투자소개서 작성을 준비하고 있던 초기 단계에서 중단된 점 등 제반 사정에 비추어 보면, 피고가 원고에 입찰절차 진행에 필요한 투자소개서 작성을 위한 자료를 제대로 제공하지 않은 행위만을 이유로 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 것으로 보기 어렵고, 그 조건성취로 인한 법률 효과를 정할 수도 없으므로, 민법 제150조 제1항에 따라 원고와 피고 사이에 피고 소유의 두산인프라코어 차이나 지분에 관한 매매계약 체결이 의제된다고 할 수 없다.”¹⁵⁾ 라고 하였다.

4) 검토

이 사건에 대해 어느 문헌에서는 “매각절차가 상당히 진행된 시점에서 피고 대주주의 협력만 있었으면 바로 매수 예정자가 정해지는 상황이었다면, 피고의 협조의무 위반이 사실상 조건의 성취에 대한 방해행위 라고 볼 수 있다.”라고 하고 있는가 하면,¹⁶⁾ 다른

12) 서울중앙지방법원 2017. 1. 12. 선고 2015가합572866 판결.

13) 서울고등법원 2018. 2. 21. 선고 2017나2016899 판결.

14) 서울고등법원 2018. 2. 21. 선고 2017나2016899 판결.

15) 대법원 2021. 1. 14. 선고 2018다223054 판결.

16) 송옥렬, “동반매도요구권과 대주주의 실사협조의무-대법원 2021. 1. 14. 선고2018다223054판결-”, BFL(서울대학교 금융법센터, 2021), 제108권, 88면.

문헌에서는 “매각절차 진행을 통해 매매상대방 확정 및 매매대금 확정이 되어 매도결정 통지를 하고 그에 따라 매매계약이 체결될 수 있다는 ‘정당한 기대권’이 있었는지 문제된다.”¹⁷⁾ 라고 하면서 통상적인 매각절차에서 실사 진행 중에도 투자자가 매수의향을 철회하는 경우가 빈번하므로 투자 소개서 작성단계에서부터 매도결정통지를 할 수 있으리라는 기대권을 확정적으로 갖기는 어렵다고 하고 있다.¹⁸⁾

이 사건에서 특이한 점은 대법원은 피고의 신의칙 위반을 인정하면서도, ‘법적구속력이 없는 인수의향서만을 제출받은 초기단계’에서 절차가 중단되었다는 것을 강조하며 원고를 민법 제150조를 통해 보호하려는 대상에서 제외시켰다는 점이다. 이러한 판례의 입장은 반대로 말하면 민법 제150조가 적용되기 위해서는 원고가 가지는 조건부 권리의 상태가 일정 수준이상으로 성숙해진 단계여야 하거나 실현될 가능성이 높은 단계여야 한다는 점을 요구하고 있다고 볼 수 있는 것이다.

(3) 투자배당금 사건(대법원 2022. 12. 29. 선고 2022다266645판결)

1) 사실관계¹⁹⁾

피고B는 전자부품 등 제조업, 인터넷 정보제공업 등을 목적으로 설립된 법인이고, 피고C는 피고B의 대표이사이다. 원고는 피고B에 투자한 투자자이다.

원고는 2007. 1. 30.경 피고B의 대표이사C와의 사이에 이 사건 투자협정서를 작성하였는데, 그 협정서 안에는 “을(B대표이사 C)은 갑(원고)에게 피고B가 보유한 지적재산권을 통한 매출 발생 시마다 당사의 수익금 중 10%를 갑의 투자금의 원금을 포함한 5배 금액이 될 때까지 배당 상환 지급키로 한다.”라는 내용이 포함되어 있었다.

원고는 2007. 1. 24.부터 2007. 8. 20.경까지 피고B에게 합계 26,000,000원을 투자하였다. 피고C는 “2009. 5.경부터 2010. 8.경까지 피고B의 제품설명회 등에서, ‘당사 제품이 곧 출시될 예정인데 유통점 계약을 체결한 사람들에게만 제품을 공급해 주겠다. 피고회사는 바로 매출 1조 원 회사가 되기 때문에 유통점주들은 모두 대박이 날 것이다’라는 등으로 거짓말을 하여 이에 속은 다수 유통점주들로부터 유통점 계약 신청금, 제품 선금금 등을 편취하였다”라는 「특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 위반(사기) 등 혐의로 기소되어 1심, 항소심에서 사기죄로 유죄판결을 선고받았고, 이 사건 제1심 선고 이전인

17) 이유진, "동반매도청구권(Drag-Along Right)에 대한 연구 - 대법원 2021. 1. 14. 선고 2018다223054 판결을 중심으로 -", 『상사판례연구』(한국상사판례학회, 2021), 제34권 제3호, 203면.

18) 이유진, 앞의 논문(주 17), 203면.

19) 대법원 2022. 12. 29. 선고 2022다266645판결.

2018. 12. 13. 에 위 사기사건은 대법원 판결 선고로 확정되었다.

원고는 이 사건 협정서에 따라 2007. 1. 24.부터 2007. 8. 20.까지 합계 26,000,000원을 투자하였으므로 이 사건 협정서에 따라 피고B는 원고에게 원고가 투자한 금액(26,000,000원)의 5배인 130,000,000원을 지급할 의무가 있다고 주장하며 약정금 130,000,000원을 청구하였다.

2) 제1심 및 항소심의 판단

제1심은 원고의 약정금 청구를 전부 기각하였다. 그 이유는, 원고가 피고B로부터 이 부분 각 협정에 따른 배당금을 지급받기 위해서는 ‘피고B가 보유한 지적재산권을 통한 매출’이 발생하였어야 하는데 피고B의 지적재산권을 이용한 매출(스마트폰 등의 제품을 생산·판매함에 따른 매출)이 발생하지 않았기 때문에 피고B가 원고에게 이 사건 협정에 따른 약정금 130,000,000원을 지급할 의무가 있음을 인정하기 어렵다는 것이다.²⁰⁾

이 사건에서 원고는 “피고B가 제3자들과 유통점 계약을 체결하여 유통점 점주들로부터 제품선급금 등의 명목으로 3,366,560,000원을 지급받음으로써 위 선급금 상당의 매출이 발생하였으므로, 이 사건 협정에 따른 배당금 지급 요건이 갖춰졌다.”라는 취지로 주장하였으나, 제1심 재판부는 이 선급금 등의 명목으로 지급받은 금원은 피고B의 ‘지적재산권을 통한 매출’이라 볼 수 없다는 이유로 원고의 주장을 배척하였다.²¹⁾

항소심은 원고의 항소를 받아들여 원고의 청구를 일부 인용하였다. 항소심에서 원고는, 피고B와 ‘피고B가 보유한 지적재산권을 통한 매출’이 발생하는 것을 ‘조건’으로 피고B가 원고에게 투자금의 5배를 배당금으로 지급하기로 하는 이 사건 투자협정을 체결하고, 그 협정에 따라 피고B에게 2,600만 원을 투자하였던 것이므로 원고의 피고B에 대한 배당금지급청구권이 존재한다는 1심에서의 주장은 유지하되, 아래와 같이 민법 제150조 제1항 소정의 ‘조건성취 방해’법리를 추가하였다.

즉, 항소심에서 원고는, 설령 ‘피고B가 보유한 지적재산권을 통한 매출’이 발생되지 않아 이 사건 투자협정에서 정한 배당금 지급조건이 성취되지 못하였더라도, 처음부터 위 조건을 성취할 의사가 없었던 피고B와 C가 신의성실의 원칙에 반하여 매출을 발생시키지 않았으므로, 민법 제 150조 제1항에 따라 위 조건의 성취가 의제되었다고 보아야 한다고 주장했다. 따라서 민법 제150조 제1항에 따라 ‘피고B가 보유한 지적재산권을 통한 매출’이 발생한 것으로 의제되어 피고B는 원고에게 협정에 따른 배당금 1억 3,000만 원

20) 대전지방법원 2020. 12. 10. 선고 2017가합104785 판결.

21) 대전지방법원 2020. 12. 10. 선고 2017가합104785 판결.

을 지급할 의무가 있다고 주장한 것이다.

이에 피고B는 원고가 이 사건 협정에 따라 배당금을 지급받기 위해서는 ‘피고B가 보유한 지적재산권을 통한 매출’이 발생한다는 ‘조건’이 성취되어야 하는데, 피고B는 매출이 발생한 사실이 없어 위 조건은 성취되지 않았으므로 피고B는 배당금지급의무가 없고, 위 조건이 성취되지 못한 이유는 원고가 피고B와의 총판계약에 따른 총판대금을 피고B에게 지급하지 못하였기 때문이고, 피고B는 제품 개발 및 양산 체제를 갖추기 위해 약 110억 원 상당의 자금을 투입하는 등 최초부터 제품을 개발하거나 생산할 의사도 있었으므로, 민법 제150조 제1항에 따라 위 조건의 성취가 의제된다고 볼 수도 없다고 주장하였다. 피고B와 C는 항소심에서 자신이 신의칙에 반하여 조건성취를 방해한 사실이 없다는 취지의 항변을 한 것이다.

이에 대해 항소심은 이 사건 투자협정의 존재 및 이 사건 투자협정 이후 ‘피고B가 보유한 지적재산권을 통한 매출’이 발생하지 않은 사실을 인정한 후, 원고와 피고B가 이 사건 투자협정에서 ‘피고B가 보유한 지적재산권을 통한 매출’발생을 배당금 지급의 ‘조건’으로 정하였음에도 그 조건이 달성되지 못한 것이므로 원고는 원칙적으로 피고B에게 이 사건 투자협정에 따른 배당금의 지급을 구할 수는 없다고 판시하였다.²²⁾

그럼에도 피고B의 대표이사 C는 처음부터 제품을 양산하여 판매함으로써 ‘피고B가 보유한 지적재산권을 통한 매출 발생’이라는 배당금 지급 조건을 달성할 의사가 없었던 것으로 보임에도, 원고로부터 투자금을 지급받기 위해 원고를 기망하여 이 사건 투자협정을 체결하였는바, 이는 신의성실에 반하여 조건성취를 방해한 때에 해당하므로 민법 제150조 제1항에 따라 위 조건이 성취되었음을 주장할 수 있다고 판단한 것이다.²³⁾

피고B의 대표이사 C가 애초에 조건성취 의사 없이 투자금을 지급받기 위해 원고를 기망하여 조건부 법률행위를 한 것 자체가 민법 제150조 제1항 소정의 ‘신의성실에 반하여 조건성취를 방해한 행위’에 해당한다고 판단한 것이다.

3) 대법원의 판단

대법원은 “민법 제150조 제1항은 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다는 법질서의 기본원리가 발현된 것으로서, 누구도 신의성실에 반하는 행태를 통해 이익을 얻어서는 안 된다는 사상을 포함하고 있지만, 일방 당사자의 신의성실에 반하는 방해행위 등이 있었다는 사정만으로 곧바로 민법 제150조 제1항에 의해 그 상대방

22) 대전고등법원 2022. 7. 20. 선고 2021나10058 판결.

23) 대전고등법원 2022. 7. 20. 선고 2021나10058 판결.

이 발생할 것으로 희망했던 결과까지 의제된다고 볼 수는 없으므로, 여기서 말하는 ‘조건의 성취를 방해한 때’란 사회통념상 일방 당사자의 방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것으로 볼 수 있음에도 방해행위로 인하여 조건이 성취되지 못한 정도에 이르러야 하고, 방해행위가 없었더라도 조건의 성취가능성이 현저히 낮은 경우까지 포함되는 것은 아니다.”²⁴⁾ 라고 하면서 “이 사건 투자협정은 피고 회사가 보유한 지적재산권을 활용하여 관련 전자제품을 개발·판매하려는 사업의 준비 단계나 초기 과정에서 체결된 것인데, 당시로서는 피고 회사가 제품을 개발 및 양산할 수 있을지, 나아가 해당 제품이 구매자 등에게 실제로 판매될 수 있을지 여부를 알 수 없는 등 해당 사업의 성공가능성을 예측하기 어려웠던 것으로 보이고, 원고로서도 위와 같은 매출 발생이라는 이 사건 조건이 성취되는 것이 쉬운 일이 아니라는 점을 인식하였던 것으로 보이고, 거기에 앞서 본 바와 같이 피고 회사의 대표이사 소외인이 해당 제품을 개발·양산하여 매출을 창출할 만한 능력이 없었음에도 다수 유통점주들로부터 제품 선금금 등을 편취하였다는 혐의로 형사처벌을 받은 점을 더하여 보면, 피고 회사의 방해행위가 없었더라도 이 사건 조건의 성취가능성은 현저히 낮았던 것으로 볼 여지가 있다.”²⁵⁾라고 이유를 대며 피고 회사의 행위는 이 사건 투자협정에서 정한 이 사건 조건의 성취를 방해한 경우로 보기 어렵다고 판단하였다.

4) 검토

본 판결은, 민법 제150조에서 말하는 ‘조건의 성취를 방해한 때’란, “사회통념상 일방 당사자의 방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것으로 볼 수 있음에도 방해행위로 인하여 조건이 성취되지 못한 정도에 이르러야 하고, 방해행위가 없었더라도 조건의 성취가능성이 현저히 낮은 경우까지 포함되는 것은 아니다.”라고 하여 민법 제150조 제1항에 의한 조건 성취의 의제효과를 인정하기 위해서는, 방해행위 유무뿐만 아니라 방해행위가 없었을 경우 조건이 성취될 가능성 현저히 낮은지 여부까지 고려해야 한다는 점을 명시적으로 판시한 최초 판례라는 점에서 의미가 있다.²⁶⁾

24) 대법원 2022. 12. 29. 선고 2022다266645 판결. 밑줄은 필자가 첨가한 것임.

25) 대법원 2022. 12. 29. 선고 2022다266645 판결.

26) 대법원 보도자료

<https://www.scourt.go.kr/news/NewsViewAction2.work?pageIndex=1&searchWord=2022%B4%D9266645&searchOption=&seqnum=1328&gubun=702> (최종방문일 2024. 9. 9.)

(4) 소결

위 세 개의 판례는 공통적으로 원고가 주장하는 조건부 권리가 실현될 가능성이 낮다든가 완전한 권리로 나아갈 만큼 성숙하지 못한 단계라는 이유로 원고를 민법 제150조를 통해 보호하기를 거부한다.

이러한 대법원의 태도는 민법 제150조 제1항에 의한 보호가 인정된 다른 판례와 대조해 봄으로써 더 선명하게 드러난다. 이른바 ELS²⁷⁾ 사건이라 불리는 대법원 2015. 5. 14. 선고 2013다2757 판결은 피고 증권회사가 삼성SDI 주식회사의 보통주를 기초자산으로 하여 중간평가일의 증가인 평가가격이 발행일의 증가인 기준가격보다 높거나 같을 경우 투자원금과 연 9%의 수익을 중도상환금으로 지급하기로 하는 내용의 중도상환조건을 내건 추가연계증권(ELS)을 발행하여 투자자인 원고에게 이를 판매한 사안이었는데, 피고 증권회사가 중간평가일의 장 종료 무렵 기준가격에 미치지 못하는 가격으로 대량의 매도 주문을 함에 따라 장 종료 10분 전까지 기준가격을 상회하던 삼성SDI의 보통주 가격이 기준가격 아래로 떨어져 원고의 중도상환조건은 성취되지 못하였던 사건이다. 이에 원고들은 피고 증권회사의 위와 같은 대량 매도주문 행위가 민법 제150조 제1항 소정의 ‘조건 성취 방해행위’에 해당한다고 주장하면서 중도상환금을 청구한 사건인데, 대법원은 피고의 행위가 없었다면 10분 후 원고가 중도상환금 지급조건이 성취되었을 상태였던 점을 고려하여 원고들의 민법 제150조 제1항 적용주장을 받아들였던 것이다.

이와 같이 판례가 민법 제150조 제1항의 요건 중 인과관계 여부를 파악함에 있어 “사회통념상 일방 당사자의 방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것으로 볼 수 있음에도 방해행위로 인하여 조건이 성취되지 못한 정도에 이를 것”을 요구하는 판례의 태도는 이하에서 보는 바와 같이 가장 직접적으로는 일본 학설의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다.

2. 일본 학설의 영향

민법 제150조가 적용되기 위해서는 ① 조건의 성취로 인하여 불이익 또는 이익을 받을 당사자가 ② 신의성실에 반하여 ③ 조건의 성취를 방해하거나 조건을 성취하였어야 한다. ③ 조건성취의 방해라는 요건은 다시 i) 방해행위의 존재, ii) 조건의 불성취 결과 받

27) 추가연계증권(ELS)이란 지수, 채권, 주식 등을 기초자산으로 내장한 구조화증권의 일종으로서 투자 수익이 특정 주권의 가격 또는 주가지수의 변동에 연계되어 결정되는 금융투자상품을 말한다. 나지수, “추가연계증권(ELS) 델타헤지거래 관련 분쟁의 분석”, 증권법연구, 제17권 제1호, 2016, 112면.

생, iii) 방해행위와 불성취사이의 인과관계가 존재할 것이라는 요건을 필요로 한다.

이 ‘인과관계’요건과 관련하여 일본의 대표적인 주석서에서는, 방해행위가 있었던 경우에도 그것이 조건의 성취·불성취와 전혀 무관한 경우 또는 방해행위가 없어도 조건이 성취하지 않는 경우에는 인과관계가 문제된다고 하면서, 예를 들어 A가 B에 대해, B가 C의 사무소에서 3년간 근무하면 100엔을 증여한다고 약속했음에도 불구하고 A가 C의 면전에서 B를 비방하여 C가 B를 해고하도록 했지만 C가 그 말을 믿지 않고 다만 그 후 다른 이유로 B가 해고되었을 때는 본조의 적용은 없다고 되어 있는데, 이것은 A의 방해행위와 조건 불성취 사이에 인과관계가 없기 때문이라고 한다²⁸⁾ 그런데 전통적인 견해는 조건부 권리의 방해행위 사안에 있어서 조건 성취 가능성을 저하(低下)시킨 정도로 인과관계가 인정될 수 있다고 파악하고 있었다.²⁹⁾

그런데 일본에서 최근까지 유력한 견해는 我妻榮 등이 주장한 견해로, 조건성취 방해사안에서 인과관계의 문제를 “방해가 없었으면 (특별한 사정이 없는 한) (조건이)성취되었을 것이라는 인정되는 경우여야 한다.”³⁰⁾ 라는 요건을 추가하여 방해가 없으면 조건이 성취되었을지 여부의 문제로 보는 학설이다.³¹⁾³²⁾³³⁾ 그 입장에서는 예를 들면 전력공급계약의 효력발생이 주무관청의 허가를 조건(법정조건)으로 하고 있는 경우에 있어서, 고의로 허가신청을 하지 않는 것이 본조에 해당한다는 것은 관청의 허가를 받아 전력을 공급할 수 있도록 한다는 계약에 있어서 신청하면 허가를 받는 것이 보통이기 때문에, 방해와 불성취 사이에는 인과관계가 있다는 것이다.³⁴⁾ 즉, 방해가 없으면 특별한 사정이 없는 한 조건이 성취되는 경우 인과관계의 존재는 긍정된다는 것이다.

특히 최근에 선고된 우리 대법원 2022. 12. 29. 선고 2022다266645 판결³⁵⁾에서는 “사회통념상 일방 당사자의 방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것으로 볼 수 있음에도 방해행위로 인하여 조건이 성취되지 못한 정도에 이르러야 하고”라고 판시하여 위 일원학설과 거의 동일한 표현을 사용하고 있음을 알 수 있다.

28) 편집대표 於保不二雄, 『新版注釈民法(4) 總則(4)』, 有斐閣, 2015, 672면(金山 집필부분).

29) 藥師寺志光, 『新訂日本民法總論新講』, 明玄書房, 1954, 936면., 편집대표 於保不二雄, 앞의 책(주 28), 672면(金山 집필부분)에서 재인용.

30) 妨害がなければ成就したであろう認めとめられる場合なければならない。

31) 我妻榮, 『新訂 民法總則(民法講義 I)』, 有斐閣, 1992, 411면.

32) 石田穰, 『民法總則』, 悠々社, 1992, 500면.

33) 편집대표 於保不二雄, 앞의 책(주 28), 673면(金山 집필부분).

34) 我妻榮, 앞의 책(주 31), 411면.

35) 위 II. 1. 다. 판결이다.

3. 사건

(1) 민법 제150조에 의해 보호되는 조건부 권리와 그렇지 못한 조건부 권리 간에는 어떠한 차이점이 있는가³⁶⁾

이와 같은 대법원 판례의 태도 즉, 민법 제150조를 적용하는데 있어서 ‘조건부 권리가 실현될 가능성이 높은 단계일 것’이라는 숨은 요건을 요구하는 판례의 태도가 어디서부터 비롯된 것인지 알기 위해 필자는 독일에서의 ‘기대권’논의를 연구한 바 있다.

조건부 권리의 보호에 관한 민법 제150조를 논의함에 있어 독일의 ‘기대권’논의를 원용할 수 있는 이유는, 독일 민법 제정위원회(Kommission)는 조건의 성취가 미정인 기간 동안에는 아직 완전권의 효력은 발생되지 않지만 장래의 권리발생을 위한 근거가 되는 조건부 법률행위 자체에는 그러한 기간 동안에도 일정한 효력이 귀속되어야 한다고 보면서 조건부 권리자는 조건 성취 시 발생하는 완전권에 대한 ‘침해할 수 없는 기대(unverbringliche Aussicht)’를 갖게 되고, 조건부 의무자는 그 기대에 구속된다고 하였고³⁷⁾, 권리나 물건을 조건부로 처분하는 경우, 거기에는 조건부 의무자가 그와 같은 권리나 물건을 달리 처분하지 못하도록 하는 이른바 ‘힘의 양도(Machtentäußerung)’가 포함된 것이라고 보면서³⁸⁾ 조건부 권리자의 문제를 기대권자의 문제로 파악하며 조건과 관련한 조문을 제정하였기 때문이다.

또한 국내 문헌에서도 조건부 법률행위에서 조건 성취 여부가 정해지지 않은 기간에 당사자가 갖는 이익은 단순한 기대를 넘어 법적 이익에 해당하므로, 위와 같은 민법 제148조 이하³⁹⁾는 이러한 조건부 권리자의 기대를 법률상 보호한다는 점을 보다 명확히 한 것이라고 하거나,⁴⁰⁾ 조건의 성부가 확정되기 전이라도 당사자는 조건의 성취로 일정한 이익을 얻을 기대를 가지고, 민법은 이 기대 내지 희망을 일종의 권리로 보호하는 바, 이 권리를 조건부 권리라고 한다고 하며, 조건 성취에 의하여 이익을 받을 당사자는 조건 성취 여부가 미정인 상태에서도 일종의 기대권을 가진다고 설명되고 있기 때문이다.⁴¹⁾

36) 이하 내용은 줄고, “민법상 조건성취 방해 범리에 관한 소고-대법원 2022. 12. 29. 선고 2022다266645 판결을 중심으로-”, 법학논집 제28권 제1호, 이화여자대학교 법학연구소, 2023, 372~378면을 요약한 것이다.

37) Motive I, S. 255.

38) 앞의 책(주 37), S. 259.

39) 민법 제148조~제150조를 말함.

40) 이동진, “조건의 성취 방해로 인한 조건의 성취 의제”, 대법원 판례해설 제133호, 법원도서관, 2023, 471면.

41) 지원림, 『민법강의』(홍문사, 2020), 375면.

필자는 조건부 권리가 기대권의 일종이라는 전제하에, 그렇다면 민법 제150조에 의해 보호되는 조건부 권리와 그렇지 못한 조건부 권리 간에는 어떠한 차이점이 있는지를 연구한 바 있다.⁴²⁾ 그 내용을 간략하게 소개 하자면, “권리취득의 법률요건이 수개로 구성되어 있는 경우에 그 권리를 취득하기 위하여 필요한 법률요건의 전부는 아직 실현되어 있지 않았으나 이미 몇 개의 법률요건이 실현되어 있으면 권리의 전(前)단계(Vorstufe)에 도달한 것이고 아직 실현되지 않은 법률요건이 적을수록 완전한 권리에 접근하며 이와 같이 완전한 권리를 향하여 발전하고 있는 과정에 있는 법적 지위를 곧 기대권”⁴³⁾ 이라고 하는데 독일의 법학자들은 주관적 권리의 취득에 대한 약한 전망은 단순한 ‘기대’ 또는 ‘희망’이라고 하고, 주관적 권리로서의 “기대권(Wartrecht)”과 구별하였다.⁴⁴⁾ 기대권자는 아직 갖추어지지 않은 나머지 요건이 방해 없이 갖추어진다고 하는 완전권 취득이익과 그렇게 취득된 이익을 타인에게 처분 하거나 담보로 제공하는 등의 방법으로 처분할 수 있다는 처분이익을 갖기 때문에 단순한 ‘기대’ 혹은 ‘희망’을 가진 사람과는 달리 법적으로 보호될 필요가 있고,⁴⁵⁾ 독일에서는 완전권을 취득하기 이전의 단계이지만 법이 보호해야 할 필요성을 느끼고 그러한 기대적 상황의 이익상태에 대해 법적으로 승인하는 것을 이른바 사전적 효력(事前的 效力, Vorwirkung)이라고 불렀다.⁴⁶⁾

독일 학자들은 단순한 전망·기대와 기대권을 어떤 기준에 의해서 구별할 것인가에 대해, 법률요건요소를 ‘단순한 효력요건’과 ‘내용관련 법률요건요소’로 구별한 후, 단순한 효력요건들의 실현이 있을 경우는 단순한 ‘희망(Hoffnung)’의 상태에 있지만, 모든 ‘내용관련적 법률요건요소’의 실현이 있을 경우는 하나의 권리에 대한 ‘기대권’을 생성케 한다고 보았다.⁴⁷⁾ 내용관련적 법률요건요소의 실현이 있어야 한다는 것은 실현된 법률요건 사실이 장차 생성될 권리와 내용관련적이라는 의미로서 결국 권리의 귀속기반 또는 내용이 되는 법률사실의 실현이 있어야 기대가 생성된다고 표현할 수 있는 것이다.⁴⁸⁾

이를 종합하여보면, 어떤 권리가 발생하기 위해서 a, b, c, d, e라는 요건이 순차로 충족되어야 한다고 볼 때, 甲이라는 사람은 a요건만을 충족시킨 상태이고, 乙이라는 사람은

42) 참고(주 36).

43) 최종길, “물권적 기대권 (1)”, 『사법행정』(한국사법행정학회, 1965), 제6권 제2호, 56면.

44) 김학동, “소유권유보부매매의 법률관계”, 『민사법학』(한국민사법학회, 2005), 제27권, 500면.

45) 김증한, “물권적 기대권론”, 『민사법학』(한국민사법학회, 1978), 제1권, 13면.

46) Hermann Fitting, 『Über den Begriff der Rückziehung』, Deichert, 1856, S. 21.

47) Forkel Hans, 『Grundfragen der Lehre von Privatrechtlichen Anwartschaftsrecht』, Duncker & Humblot, 1962, S. 45.

48) 황성일, “등기전부동산매수인의 법적지위에 관한 연구”, 성균관대학교 석사학위청구논문, 2009, 18면.

a부터 d까지를 충족하여 e라는 요건만 남은 상태라면 법질서가 甲과 乙의 기대적 상황을 법적으로 동일하게 보호하는 것은 정당화 될 수 없을 것이다. 따라서 乙이 장차 생성될 권리의 내용관련적 요소를 이미 '실현'시켰다면 그렇지 못한 사람에 비해 우대받을 필요가 있는 것이고, 독일법에 영향을 받은 우리나라는 전자와 같은 사람을 보호하기 위해 “일방 당사자의 방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것으로 볼 수 있음에도 방해행위로 인하여 조건이 성취되지 못한 정도에 이르러야 하고, 방해행위가 없었더라도 조건의 성취가능성이 현저히 낮은 경우까지 포함되는 것은 아니다.”라고 선언하고 있는 것이라 이해해 볼 수 있다고 생각한다.

(2) 한계점

그러나 위와 같은 시각을 통해 판례의 입장을 이해하고자 하는 경우에도, 그렇다면 “방해행위가 없었더라도 조건의 성취가능성이 현저히 낮다.”라는 기준이 명확한 것인지는 의문이다. 방해행위가 없었다면 조건이 성취될 확률이 50%이상이면 민법 제150조의 적용대상이 되는 것인가? 30%이상이면 적용대상이 되는 것인가?

또한 판례 문구 중 “일방 당사자의 방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것으로 볼 수 있음에도 방해행위로 인하여 조건이 성취되지 못한 정도에 이르러야 하고”라는 표현에서는 조건부 권리가 완전권에 근접할 정도로 상당 부분 진척이 되었어야 함을 요구하는 것처럼 보이는데, “방해행위가 없었더라도 조건의 성취가능성이 현저히 낮은 경우까지 포함되는 것은 아니다.”라는 표현은 조건부 권리의 성취가능성이 매우 낮은 경우만 제외한다는 뜻으로 받아들일 수 있기 때문에 본조의 적용대상이 어느 정도의 조건성취가능성을 지닌 조건부 권리를 말하는 것인지 가늠하기가 여전히 쉽지 않다.

또한 다른 국내문헌에서는, 방해행위가 없었더라도 조건의 성취가능성이 현저히 낮은 경우'를 본조의 적용범위에서 제외시키는 판례의 태도에 대해, 불능조건과의 구별문제를 발생시킨다고 지적하는데⁴⁹⁾ 이는 타당한 지적이다. 불능조건이란 객관적으로 실현 불가능한 사실을 내용으로 하는 조건을 말하는데,⁵⁰⁾ 민법 제151조 제3항에 따르면 불능의 정지조건을 부가한 경우 그 법률행위는 무효가 된다. ‘방해행위가 없었더라도 조건의 성취가능성이 현저히 낮은 경우’에 대해서 본조의 적용에서 제외시킬 경우, 결국 이러한 경우에 있어서는 불능조건과 동일하게 취급되는 결과가 되는데, 성취가능성이 현저히 낮다는 것과 객관적으로 불능이라는 것은 법률상 구분이 가능함에도 동일하게 취급한다는 것은

49) 권오상, 앞의 논문(주 2), 47면.

50) 편집대표 양창수, 『민법주해 4』(박영사, 2022), 223면.

불합리하다는 생각이 든다.

또한 민법 교과서에서 조건이 무엇인지 설명하면서 가장 흔하게 드는 예가 “결혼하면 집을 한 채 주겠다.”라는 예인데,⁵¹⁾ 우리 판례의 태도를 일관하자면, 약정 시에 결혼이 불가능하지는 않지만 그 가능성이 현저히 낮은 사람(예를 들어, 수증자가 고등학생인 경우)은 민법 제150조에 의해 보호받을 수 없게 된다. 그런데 위의 예에서 얼마든지 해당 고등학생은 결혼을 할 수도 있기 때문에 혼인신고 후 증여자에게 위 약정에 기해 집을 청구할 수 있는 것이고 그의 이러한 기대가 법적으로 보호가치가 없다고 평가하기도 힘들다. 그런데 판례의 논리에 따르면 위의 고등학생인 수증자는 민법 제150조에 의한 보호를 받을 수 없게 되어, 위와 같이 교과서에서 예로 등장할 정도로 대표적인 조건부 권리에 대해서도 본조가 적용되지 않는다는 다소 받아들이기 어려운 결과에 직면하게 된다. 이러한 점을 생각하여 보면, ‘사회통념상 조건 성취의 가능성이 약간이라도 있는 경우에는 본조를 적용하여야 한다.’라고 하는 일본 주석서의 결론이⁵²⁾ 이해가 가는 면이 있다.

III. 인과관계와 관련한 특수한 문제

1. 조건부 권리와 가정적 인과관계의 문제

(1) 조건부 법률행위의 특수성

조건부 법률행위의 경우, 불확실한 미래의 사실이 실현되는지 여부에 따라 법률행위의 효력이 좌우된다. 이처럼 불확실성(不確實性)은 조건의 가장 핵심적인 성질인 것이다.⁵³⁾ 그런데 이러한 불확실성은 다른 말로 ‘가능성’이라고 부를 수 있을 것이고, 만약 어떠한 조건이 성취될 가능성이 30%라면, 그 조건이 성취되지 않을 가능성은 70%라고 할 수 있는 것이다. 이와 같이 조건부 법률행위는 태생적으로 불확실성 혹은 요행성을 띠고 있기 때문에, 조건성취를 방해하는 행위를 했다고 지목받는 조건부 의무자 입장에서는 ‘나의 방해행위가 없었더라도 어차피 조건이 성취될 확률은 낮았다.’라고 하면서 자신의 행위와 조건의 불성취사이에 인과관계가 없다고 주장할 수 있다. 이렇게 현실

51) 송덕수, 앞의 책(주 5), 203면.

52) 편집대표 於保不二雄, 앞의 책(주 28), 673면(金山 집필부분).

53) 이주은, “개정 프랑스민법상 조건부 채무”, 『아주법학』(아주대학교 법학연구소, 2018), 제12권 제3호, 181면.

적인 가해행위 당시에 가해행위가 없었더라도 어차피 동일한 손해를 발생시킬 것으로 인정되는 잠재적인 사정 혹은 제2차적 사정이 존재하는 경우, 이러한 잠재적·2차적 사정으로 인해 현실적 손해원인 야기자의 책임이 면책되거나 경감되는지의 문제는 인과관계 영역에서 소위 가정적 인과관계(hypothetische Kausalität, 假定的 因果關係)라는 이름으로 논해진다.⁵⁴⁾⁵⁵⁾

그리하여 가정적 인과관계의 문제는 조건성취 방해의 국면에서는, 그 조건이 성취되지 않을 가능성(조건성취의 불확실성)이 방해행위(가해행위)와 별도로 존재하는 잠재적 사정으로 고려되어 방해자가 면책 또는 책임의 경감을 주장할 수 있을지의 문제로 나타나게 된다.

(2) 학설의 대립

그런데 현재 우리 민법학계에서는 민법 제150가 적용되기 위한 요건 중 ‘인과관계’에 관하여 ‘방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것이라는 (가정적) 인과관계가 요구되는지’에 대해서 학자들 간에 첨예하게 견해가 대립되고 있다.

위와 같은 가정적 인과관계가 필요하다는 견해(이하 ‘가정적 인과관계 필요설’이라고 함)는, 독일에서는 어떠한 행동을 조건의 성취 또는 불성취로 평가함에 있어서는, 문제되는 행동이 없었더라면 조건이 성취되거나 성취되지 않았을 것이라는 증명(신의성실에 반하는 당사자 행동의 인과성)이 있어야 한다고 보고 있고, 그 근거는 독일 민법 제162조의 규범 목적은 사건의 경과를 규칙에 어긋나는 방해로부터 보호하려는 데 있는 것이지 행동에 대한 제재에 있는 것이 아니기 때문에 상대방이 신의칙에 반하는 행동이 있었다고 확인되더라도 오히려 인과관계가 증명되어야 한다는 점을 들고 있다고 보고 있다.⁵⁶⁾

가정적 인과관계가 필요하지 않다는 견해(이하 ‘가정적 인과관계 불요설’이라고 함)는, 방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라는 것에 대한 입증은 실제 극히 곤란하고, ‘방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것’이라는 가정적인 사정까지 조건부 권리자에게 증명하도록 한다면 조건부 권리의 보호를 불완전하게 할 염려가 있으므로 방해행위로 조건 불성취의 결과가 초래되었다면 민법 제150조가 적용된다고 할 것이고, ‘방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것’이라는 인과관계를 요구하는 것은 문언

54) 임건면, "가정적 인과관계", 『성균관법학』(성균관대학교 법학연구소, 2004), 제16권 제2호, 205-206면.

55) 양삼승, "손해배상과 잠재적·후발적 사정", 『민사법학』(한국민사법학회, 1982), 제3권, 5-6면.

56) 윤진수, 앞의 논문(주 2), 335-338면. 권오상, 앞의 논문(주 2), 42-43면.

에도 없는 가정적 인과관계로서 본 규정을 지나치게 좁게 해석하게 만들고, 위 민법규정이 가지는 규범적 의미를 저해한다고 한다.⁵⁷⁾ 오히려 ‘방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것’에 대한 ‘개연성’이 있다면, 이는 본 규정의 요건인 ‘신의성실에 반하여’ 조건의 성취를 방해한 것에 해당하는지를 판단하는 사정요소(事情要素)로서 참작할 수 있을 것이라고 한다.⁵⁸⁾⁵⁹⁾

그렇다면 민법 제150조의 적용을 주장하는 조건부권리자는 ‘방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것’이라는 가정적 인과관계까지 증명해야 하는가?

(3) 각 학설의 필요성 및 각 학설을 취할 경우 나타나는 결과와 불합리성

국내 문헌들은 민법 제150조에서 규정하는 조건 성취의 방해는 조건부 권리침해의 한 유형이므로 민법 제150조는 민법 제148조의 특별규정이라고 한다.⁶⁰⁾

그리고 민법 제148조의 침해로 발생할 책임의 법적 성질에 대하여는 불법행위에 의한 손해배상청구권이라는 견해⁶¹⁾와 채무불이행으로 인한 손해배상청구권이라는 견해⁶²⁾, 채무불이행책임 뿐만 아니라 불법행위로 인한 손해배상 책임을 경합적으로 인정할 수 있다는 견해⁶³⁾ 등이 대립하고 있으나 그 성질이 ‘손해배상책임’이라는 점은 공통된다. 그렇다면 어느 견해에 따르더라도, 민법 제150조의 조건부 권리의 침해로 인해 발생할 책임의 법적 성질은 손해배상책임이라고 할 수 있다.

그런데 우리나라는 일반적으로 손해배상책임에서 ‘손해’의 의미를 이른바 차액설(差額說)에 따라 판단하고 있다. 즉, 위법한 행위가 없었더라면 존재하였을 재산상태와 위법행위가 가하여진 현재의 재산상태의 차이⁶⁴⁾를 손해로 관념하는 것으로, 과잉배상을 막는 역할을 한다. 위와 같이 가정적 원인을 고려하는 ‘인과관계 필요설’은 손해에 관한 ‘차액설’에 기초를 두고 있다고 볼 수 있다.⁶⁵⁾

57) 양창수, 앞의 논문(주 2), 296-297면.

58) 양창수, 앞의 논문(주 2), 296-299면.

59) 그 외에 방해행위와 인과관계의 구별을 주장하는 견해로 이상훈, “최근 ELS 소송에서의 민법 제150조 제1항 적용의 쟁점과 함의”, 민사법학 제76호, 2016. 25면.

60) 편집대표 박윤직, 『민법주해(III)-총칙』(박영사, 1992), 360면(민형기 집필부분).

61) 박윤직·김재형, 앞의 책(주 5), 406면.

62) 이영준, 『민법총칙』(박영사, 2007), 772면; 김상용, 『민법총칙』(화산미디어, 2009), 693면.

63) 김주수, 『민법총칙』(삼영사, 2013), 507면; 김증한·김학동, 『민법총칙』(박영사, 2013), 626면.

64) 대법원 1992. 6. 23. 선고 91다33070 전원합의체 판결.

65) 이 견해에 있는 학자들은 독일민법 제249조 제1항(배상의무자는 배상의무를 부담해야 할 사정이 발생하지 않았더라면 존재했을 상태를 회복하지 않으면 안 된다)에 근거하고 있다. 독일민법 제249조 제1항에 의하면 배상의무자는 가해행위가 없었으면 존재하였으리라고 생각되는 재산상태를 창조

그런데 이 ‘차액설’에 충실하게 손해를 바라볼 경우, ‘가정적 인과관계’상황에서는 불합리한 상황이 초래될 수 있다. 다음 예를 통해 잠재적·제2차적 사정을 고려하는 것이 어떠한 불합리한 상황을 초래하는지 생각해볼 수 있다.

사례 4.⁶⁶⁾

원고 X는 피고 Y에 대하여 X소유 가옥의 관리인으로서 그 가옥의 임료를 징수하고 이를 H은행에 투자할 것을 위임하였다. Y는 그 약속을 위반해서 그 징수한 임료를 횡령하고 H은행에 투자하지 아니하였다. 그런데 H은행은 그 후 곧 파산하게 되어 그 은행의 모든 채권자는 그 채권액의 15%만을 배당받게 되었고 이후 15%를 추가로 배당하겠다고 약속하였다. 이 경우 X가 Y를 상대로 제기한 손해배상청구소송에서 Y는 다음과 같이 항변하였다. 즉, Y가 X와 합의한 대로 징수한 임료를 H은행에 투자했다 할지라도 그 후에 H은행이 파산하였으므로 X는 H은행의 다른 채권자들과 마찬가지로 투자액의 30%만을 배당받을 수 있었을 것이기 때문에 Y는 자기의 횡령금액의 30%의 배상의무만을 가질 뿐이라고 주장하였다.⁶⁷⁾ 이 경우 Y의 항변은 타당한가?

위 사례에서 차액설을 그대로 적용한다면, 제1차 사건(횡령)에 의하여 발생한 손해 중 70%는 다른 원인(제2차 사건, 은행의 파산)에 의하여 어차피 발생하였을 것이기 때문에, 제1차 사건에 의하여 피해자의 총재산상태는 아무런 변화가 없어⁶⁸⁾ 1차 사건의 가해자는 은행이 제시한 30%이상은 손해를 배상할 필요가 없게 된다. 그런데 이러한 결과는 위법한 가해행위(위 사안에서 횡령)를 한 사람이 후발적 사정(위 사례에서 은행의 파산)에 자신의 위법성을 희석시키는 듯한 인상을 준다.

차액설을 조건부 권리의 침해문제에 적용해 보자. 조건부 권리자 A가 있고 B라는 사람이 조건성취를 방해했다고 지목받고 있다. 이 경우 A가 민법 제150조 제1항에 의한 법적 효과를 주장하려 할 때, 손해개념에 관한 차이설에 근거를 두고 있는 가정적 인과관계 필요설에 의하면 A는 ‘B의 방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것이라는 점’을 증명해야 한다. 그러나 조건사실이란 불확실한 미래의 사실로서 요행성을 띠고 있다. 따라서 B로서는 그러한 조건사실의 불확실성을 이유로 ‘나의 방해 행위가 없었더라도 조건이

할 의무가 있기 때문에, 잠재적·후발적 사정으로 인해, 현실적 손해원인에 의해서 야기된 상태와 현실적 손해원인이 없었더라면 존재하였을 것이라고 인정되는 상태와의 차이만큼 가해자는 책임을 지게 된다. 따라서 가정적 원인을 고려하는 입장을 취하게 되는 것이다.

66) 독일 제국법원 1933. 7. 13. 판결의 예이다. 윤진수, “가정적 인과관계 및 후발적 손해확대에 관한 고찰”, 비교사법 제30권 제4호, 한국사법학회, 2023, 164면 참조.

67) 양삼승, “가정적 인과관계에 대한 고찰(하)”, 『법조』(법조협회, 1980), 제30권 제2호, 64면.

68) 임건면, 앞의 논문(주 54), 206면.

성취되지 않았을 것이다.’라고 주장하여 민법 제150조 제1항의 책임에서 면책될 것을 주장할 수 있다. 조건사실이 본질적으로 지니고 있는 불확실성, 즉 이루어지지 않을 수 있는 확률이 존재하기 때문에 B의 주장은 엄연한 사실이기 때문이다. 모두에서 제시한 두 번째 사례를 예로 들어보면, 시험 날 아침 알람시계를 끄고 집을 나가버린 B는 A에게 통계적으로 공무원 시험의 합격률은 30%에 불과하고, A가 학창시절 공부를 잘하지 못했다는 사정을 들어 면책을 주장할 것이다. 그 상황에서 A에게 ‘B의 방해행위(알람시계를 끄고 집을 나가버린 행위)가 없었더라도 시험에 합격했을 것’을 증명하게 한다면 이 증명은 과연 가능한 것일까?⁶⁹⁾ 인과관계 불요설의 입장에서 “방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라는 것에 대한 입증은 실제 극히 곤란하다.”⁷⁰⁾라는 근거를 드는 것은 이러한 면에서 이해가 가능한 것이다.

그러나, 반대로 잠재적 사정이라고 할 수 있는 조건사실의 불확실성을 고려하지 않고 방해행위가 없었더라도 조건이 성취되었을 것이라는 점에 대한 증명을 요함이 없이 바로 조건성취를 의제하게 되면, 조건사실이 지니는 불확실성에도 불구하고 모든 책임을 방해자가 지는 결과가 되어 방해자는 자신이 행한 만큼만 책임을 진다는 원칙을 위반하게 되고, 조건부 의무자는 방해행위가 없었던 경우보다 더 유리하게 됨으로써⁷¹⁾ 과잉배상을 초래하게 된다.

위와 같이 민법 제150조의 인과관계에 있어서 가정적 인과관계 즉, ‘방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었을 것’이라는 점에 대한 증명을 필요로 하는지의 문제는 우리 법이 일반적으로 따르고 있는 손해개념인 차액설을 따라가자니 조건부 법률행위의 특수성을 간과하게 되고, 조건부 법률행위의 특수성을 따라가자니 우리 민법의 손해개념인 차액설과 일관하지 못하는 결과를 나타낸다. 따라서 가정적 인과관계의 증명이 필요하다 또는 불요하다는 두 입장 모두 각자의 난점을 지니고 있다.

2. 기회상실론 차용 가능성

(1) 기회상실론의 등장 이유

기회상실론(la théorie de la perte de chance)은 프랑스에서 창안된 이론이고 영국과

69) 이 경우 통계적 합격률이 50% 이하인 시험합격을 조건으로 하는 수험생에 대해서는 항상 위 증명이 어렵다고 볼 수 있을 것이다.

70) 양창수, 앞의 논문(주 2), 296면.

71) 윤진수, 앞의 논문(주 2), 338면.

미국에서도 논의되고 있는 이론이다. 국내에서 기회상실이론은 주로 의료사고와 관련하여 치료기회 상실을 '손해'로 볼 수 있는지의 문제로 논의되고 있다.

피해자가 가해자로부터 손해배상을 받기 위해서는 위법한 가해행위(채무불이행 또는 불법행위), 손해 그리고 양자 사이의 인과관계를 입증하여야 하는데, 전통적인 견해에 따르면 손해의 존부 및 액수의 개연성의 정도가 51% 이상이면 손해배상을 받을 수 있고, 그 미만이라면 손해배상을 전혀 받지 못하게 된다. 이러한 '전부 또는 전무'라는 원칙(all-or-nothing rule)의 경직성을 완화하는 장치로 모색된 것이 기회상실이론으로서, 가해행위로 인하여 손해의 발생가능성이 50% 이하인 경우에도 그 확률의 정도에 따라 기회의 상실에 따른 손해배상을 인정하려는 이론이다.⁷²⁾

'인과관계'라 함은 원칙적으로 행위의무위반과 결과(손해) 사이에 연계성이 존재하는가 아닌가에 따라 그 존재여부만을 판단할 뿐, 어느 정도의 연계성이 존재할 때 인과관계가 존재하는 것으로 판단할 것인가가 문제되는 것은 아니다. 결국 어느 정도의 연계성을 가질 때 인과관계가 존재하는 것으로 평가 판단할 것인가의 문제는 이른바 증명도의 문제라 할 수 있는데 전통적인 책임법론에서는 이른바 all or nothing의 원칙을 고수하고 있지만, 예컨대 51% 이상의 가능성이 있으면 인과관계를 인정하게 되고 그 가능성이 50%이하일 경우에는 인과관계가 존재하지 않는 것으로 판단하게 된다는 설명도 실제로는 인과관계의 인정여부에 대한 가정적인 설명방법에 지나지 않는다.⁷³⁾

그리하여 기회상실이론에서는 권리자가 원하는 결과를 기대할 수 있는 확률 그 자체를 법적으로 파악한 후, 침해자의 행위로 인하여 그 기회가 상실된 경우 그 상실된 기회(의료과오의 경우 '생존 가능성') 자체를 법적으로 파악하여 상실된 비율만큼 손해를 배상하려는 입장을 취하고 있다.

(2) 조건성취 방해 법리와 유사성

기회상실이론에서 논의되는 사례들은 다음과 같은 특성을 지닌다.⁷⁴⁾

72) 이창현, "수익기회의 상실과 손해배상", 『법학논총』(한양대학교 법학연구소, 2014), 제31권 제1호, 359면.

73) 김민규, "수진기회상실론- 일본의 판례 및 학설 발전으로부터의 시사 -", 『재산법연구』(한국재산법학회, 2006), 제22권 제3호, 317면.

74) 이재우, "불법행위법상 인과관계에 관한 연구", 연세대학교 박사학위 청구논문, 2015, 136-37면.

1. 행위자의 과책이 있거나 책임을 유발하는 행위 또는 사실이 있다.
2. 기대이익(enjeu)이 있다.
3. 기대이익에 요행적 성격(caractère aléatoire)이 있다.
4. 모든 사건에서 과책(faute)과 결과(résultat) 사이의 인과관계를 결부시키는 것이 불가능하다고 할지라도, 침해 안에 요행성(aléa)을 찾을 수 있다면 얻을 수 있는 기회에 대한 또 다른 침해의 배상을 구할 수 있다.

조건부 법률행위를 하는 두 당사자는 장래의 ‘불확실한 사실’에 법률행위 효력발생 여부를 의존케 한다. 두 당사자는 조건사실이 발생할 확률에 비례하는 기대이익을 가지게 되므로 그들의 기대이익은 ‘요행적’성격을 지닌다. 조건사실이 지니는 요행성으로 인하여 방해행위와 결과 사이의 인과관계를 조건적으로 결부시키는 것이 불가능한 경우가 많다. 위와 같은 요소들로 인해 조건부 법률행위에서 조건부권리자가 가지는 법적 지위와 기회상실이론에서 논의되는 사례들은 유사한 구조에 있음을 알 수 있다.

앞서 논의한 바와 같이 우리 민법은 기대 중에서 법적으로 보호받을 만한 가치가 있는 것을 제148조 내지 제150조의 조항을 통해 보호하고 있다.

기회상실이론에서 권리자가 가지는 법익과 조건부 법률행위에서 조건부 권리자가 가지는 법익(法益) 사이에는 유사성이 크다. 권리자는 ‘운’ 혹은 ‘불확실성’이라는 요소를 포함한 기대이익을 가지게 되고 이를 보호하려는 것이 법의 목적이다. 그런데 침해자의 어떠한 행위로 그 기대권이 상실 되었을 때, 침해행위와 독립적으로 작용하고 있던 운 또는 요행성이라는 요소 때문에 침해행위가 없었더라면 그러한 결과가 발생하지 않으리라는 점을 증명하는 것은 사실상 불가능해진다. 예를 들어 생존 확률이 49%인 질병에 걸린 환자가 의사의 과실로 사망에 이르렀을 때, 의사로서는 자신의 과실(침해 행위)이 없었더라도 환자가 사망할 확률이 51%나 되었기 때문에 자신의 과실과 환자의 사망 사이에는 인과관계가 없다고 주장할 수 있다. 조건부 법률행위에서 조건성취를 방해한 방해자의 입장에서조차 조건이 성취되지 않을 확률이 존재했기 때문에 자신의 방해행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라는 증명은 불가능한 것이라고 주장할 수 있는 것이다.

이러한 유사성은 모두 권리자가 지닌 기대이익에 일정한 불확실성(운, 혹은 요행성이라고 설명할 수도 있을 것이다)이 작용하고 있고 그것은 침해 또는 방해행위와는 독립적으로 작용하고 있기 때문에 일반적인 인과관계를 적용하는 것이 불합리하다는 점이다.

또한 애초에 요행적인 기대이익을 가지는 조건부 권리자에게 개연성 정도에 불과한 가능성으로 조건부 권리자를 우대하는 것은 불공정하다는 것이 가정적 인과관계에 대한 증명을 요하는 입장의 주요 논지인데, 기회상실이론은 이러한 논지를 극복할 가능성을 발

견할 수 있게 해준다.

3. 소결

(1) 기회상실론 차용으로 공평한 결과에 다가갈 수 있음

손해개념에 관하여 일반적인 개념으로 받아들여지고 있는 차액설(差額說)을 받아들이는 한, 조건부 권리에 어떠한 행위를 한 침해자는 자신의 행위가 없었더라도 조건이 성취되지 않았을 것이라는 점을 주장하면서 면책되려고 할 것이다. 조건부권리에 존재하는 불확실성 혹은 요행성은 인과관계 증명을 불명확하게 함으로써 침해자로 하여금 책임으로부터 도피할 수 있는 길을 열어주고, 동시에 인과관계가 불확실한 상황에서 피해자에게 완전배상을 해 준다는 것은 피해자가 피해 사실 이전의 상태보다 더 나은 상황에 놓여서는 안 된다는 이른바 과잉배상 금지의 원칙에 의해 배제되어야 한다고 여겨지게 될 것이다.

그럼에도 불구하고 민법 제148조는 조건부 권리를 침해하는 행위를 금지함으로써, 민법 제150조는 조건부권리에 대한 방해가 있을 시 조건성취를 의제하는 조항을 둠으로써 조건부 권리를 강력하게 보호하려고 하고 있다.

전 세계적으로 이미 차액설에 기한 손해개념은 널리 받아들여지고 있어 이러한 차액설에 근거한 사고방식 즉, 가정적 인과관계를 고려해야한다는 사고방식을 일방적으로 배척할 수는 없는 노릇이다. 그렇다고 하여 어떠한 행위를 한 자를 조건부권리가 가지는 불확실성으로 도피하게 할 수도 없는 노릇이기에 가정적 인과관계를 단순히 고려·불고려 한다는 일도양단식의 해결책은 바람직하지 않다고 생각한다. 그렇다면 행위자가 기여하여 조건부권리자의 기대이익을 감소시킨 만큼 책임을 지도록 하는 절충설적 방법을 취하는 것을 생각해 볼만하다. 그러한 절충적 해결방식에 차용할 만한 이론이 이른바 ‘기회상실이론’으로서, 조건부 권리자가 가지고 있던 확실성 있는 기대이익 자체를 보호할 법익으로 파악하고 조건부권리자가 그 기대이익을 감소시켰다면 그에 비례하여 인과관계와 책임 또한 성립시키는 것이 바람직하다는 생각이다.⁷⁵⁾

조건부 권리자가 가지는 기대이익이 일정한 수치로 계산될 수 있다는 점에서 미국에서

75) 현재 일본에서도 구체적인 내용은 상이하나, 일본민법 제130조(우리나라의 제150조와 유사한 내용)의 인과관계 문제에 있어 일도 양단적 해결이 아니라 보상을 비율적으로 인정해야 한다는 주장이 있었고, 근시에는 그 발상으로부터 본조의 효과를 비율적으로 다루자는 견해가 유력하다고 한다. 편집대표 於保不二雄, 앞의 책(주 28), 685면(金山 집필부분).

기회상실이론을 주장하는 King교수가 말하는 개연성의 승수적 원칙⁷⁶⁾도 조건부 권리의 방해에 있어서 고려해 볼 수 있다고 생각한다. 만약 합격 확률이 70%인 시험을 준비하는 원고에 대해 피고가 합격 시 1억 원을 주겠다고 약속한 상태에서 피고가 원고의 시험응시를 방해했다고 가정해 보자. 그렇다면 원고의 기대이익은 1억 원 $\times$ 70%=7천만 원이 되고, 교통체증 등 교통문제로 시험장에 들어가지 못할 확률이 20%라고 한다면(들어갈 확률은 80%) 원고의 기대이익은 1억 원 $\times$ 70% $\times$ 80%=5천 6백만 원이 된다는 식으로 계산할 수 있다.

여기서 피고는 원고로 하여금 시험장에 들어가지 못하도록 방해한 것이므로 시험장에 들어갈 확률은 80%에서 0%로 감소한다. 이 경우 기대이익은 1억 원 $\times$ 70% $\times$ 0%=0원이 되었다. 이 경우 가정적 인과관계 불고려설에 따르면 원고는 1억 원 전부를 피고에게 청구할 수 있으나 위와 같은 가정적 인과관계를 고려하되 애초에 원고가 가졌던 기대이익을 반영하는 방식에 따르면 원고는 기대이익 상실분인 5천 6백만 원만을 청구할 수 있게 된다.

(2) 사안예의 적용

이하에서는 필자가 제안하는 민법 제150조에서의 ‘기회상실이론’의 차용가능성의 적합성을 검증하기 위하여 본고에서 제시되었던 사안을 들어 본다.

위 II. 1. 가.에서 제시된 변호사성공보수 사건(대법원 1979. 6. 26. 선고 77다2091사건)의 예를 들어본다. 민사소송 항소심에서 원고의 승소가능성은 통계적으로 산정가능하다. 예컨대 민사소송 항소심에 있어 통상 원고가 승소하는 확률이 40%라고 가정해보고, 성공보수금으로 약정한 금액이 1,000만원이라고 가정해보자. 그렇다면 원고의 소송대리를 맡은 변호사가 성공보수금으로 기대할 수 있는 기대이익은 1,000만원 $\times$ 40%=400만 원이다. 그런데 성공보수금채권의 채무자인 원고가 소를 일방적으로 취하함으로써 변호사

76) 미국의 King교수는 침해행위로 인하여 감소된 법익에 비례하여 침해자에게 손해를 배상케 하는 이른바 ‘비율적 손해배상’을 주장한다.(Joseph H. King, Jr., "Causation, Variation, and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Condition and Future Consequence", The Yale Law Journal, 제90권 제6호, 1981, 1376~1378면.) 결과 발생에 다수의 사실이 원인이 되는 경우 이를 종합적으로 고려해야 한다고 주장하고 그 결과는 수학적으로 승수의 원칙에 의해 나타난다고 하는데, 예를 들어 암환자의 암 치료율이 70%일 때 진단에 의하여 암이 발견될 가능성이 60%라면 치료기회의 상실은 70% $\times$ 60%=42%로 나타난다는 것이다.(Joseph H. King, Jr. "Reduction of Likelihood Reformulation and Other Retrofitting of the Loss-of-Chance Doctrine", University of Memphis Law Review, 1998, 495면.). 자세한 내용은, 필자의 “민법상 조건(條件)법리에 관한 연구-민법 제150조를 중심으로-”, 이화여자대학교 박사학위청구논문, 2024, 198-202면 참조.

가 수령한 성공보수금은 0원으로 감소하였다. 그렇다면 이 사건에서 변호사의 기대가 보호받을 만한 기대권에 해당하고, 원고의 행위가 신의칙에 반하는 반신의행위에 해당한다면 변호사로서는 원고의 행위가 민법 제150조 제1항 위반이라고 주장할 수 있을 것이다. 그런데 기존의 학설대로 가정적 인과관계를 요구한다면 변호사로서는 원고의 행위가 없었다면 변호사로서는 의뢰인의 소취하 행위가 없었더라면 성공보수 1,000만 원을 수령할 수 있었음을 증명하여야 할 것이다. 그러나 소송의 결과라는 것은 늘 불확실성 하에 있으므로 변호사로서는 자신이 100% 승소하리라고 증명하는 것은 거의 불가능하다. 그렇다고 하여 또 다른 학설대로 가정적 인과관계를 증명하는 것이 필요 없다고 하면, 의뢰인인 원고로서는 변호사가 소송을 수행하여 패소를 할 확률이 60%나 됨에도 불구하고 1,000만원의 성공보수 전액을 지급해야 되어서 변호사가 부당하게 이득을 취한다고 느끼게 될 것이다. 이 경우 기회상실이론을 적용하게 되면 변호사는 애초에 400만원의 기대이익을 가지고 있었던 것이므로 의뢰인인 원고의 행위로 그 기대이익을 얻지 못한 결과에 대해서는 400만원에 대한 인과관계를 인정하고 손해배상도 400만원에 대해서 하도록 하는 것이 공평할 것이다.

일본에서는 위 I.의 사례 3. 과 같이 중개보수를 면탈하기 위해 부동산중개인을 배제하고 직접 계약을 체결한 경우에 있어서, 중개인의 ‘기여도’를 기준삼아 비율적으로 손해를 배상해야 한다는 주장이 과거부터 있었고,⁷⁷⁾ 근시에는 일본 민법 제130조(우리 민법의 제150조에 해당)문제를 비율적으로 다루자는 견해가 유력하다고 한다.⁷⁸⁾⁷⁹⁾ 구체적인 방법에 있어서는 상이하나, 조건성취방해 사안에 있어서 all or nothing이 아닌 비율적 보상의 방법으로 접근해 볼 수 있다는 주장이 필자의 독자적인 주장만은 아님을 알 수 있다.

77) 松岡誠之助, 『ジュリスト』161号, 法律時報, 1958, 62면. 편집대표 於保不二雄, 앞의 책(주 28), 685면(金山 집필부분)에서 재인용.

78) 편집대표 於保不二雄, 앞의 책(주 28), 685면(金山 집필부분).

79) 그러나 이 견해에 대해서는 일본 민법 제130조(우리 민법 제150조)의 효과가 과연 맞는가하는 지적이 있다. 일본 민법 제130조(우리 민법 제150조)의 효과는 all or nothing이어야 하기 때문에 비율적 처리는 일본 민법 제138조(우리 민법 제148조)에 근거한 것이어야 한다는 주장인 것인데(西宮和夫, 『民法總則』, 弘文堂, 2010, 345면) 이 지적은 필자에게 동일하게 적용될 수 있는 지적이라 생각한다. 이를 해결하기 위해서는 궁극적으로 본조의 취지를 어떻게 파악할 것인가를 근거로 하여 한 단계 더 나아간 연구가 필요하다고 통감하는 바이다.

IV. 결 론

민법 제150조는 과거에는 잘 활용되지 않았으나 최근에 그 적용을 주장하는 실무자와 법학자들이 많아지고 있음에도 민법학자들에 의한 연구는 부족한 상태여서 필자는 이 조문에 대해 연구해 볼 필요성이 있다고 생각하였다.

현재 민법 제150조에 대해 판례를 검토한 결과, 우리 대법원은, 단지 ‘조건부 권리’이 기만 하면 본조의 적용대상이 되는 것이 아니라 조건부 권리의 성숙성(가능성)을 기준으로 제150조에 의한 보호여부를 결정하는 태도를 보이고 있다는 결론을 내리게 되었다. 이러한 판례의 태도는 가장 직접적으로는 일본 학설의 영향을 받은 것이었고, 그 배경에는 단순한 기대와 주관적 권리로서의 기대권을 구별하는 독일학자들의 기대권에 관한 논의가 영향을 미쳤다는 결론을 내릴 수 있었다. 그러나 이렇게 본조의 적용대상을 구분하는 판례의 태도가 적절한지에 대해서는 의문이다.

그리고 민법 제150조의 요건 중 ‘인과관계’에 대해서는, 조건부 권리가 가지는 불확실성이라는 태생적 특수성으로 인해, ‘방해행위가 없었다면 조건이 성취되었을 것인가’라는 가정적 인과관계의 증명을 전적으로 요구하거나 전적으로 요구하지 않는 현재의 학설 대립은 한계점이 있음을 지적하면서 대안적으로 기회상실이론을 차용하여 비율적인 손해배상을 할 수 있음을 제안하였다.

원고 접수일 : 2024년 12월 4일

게재 심사일 : 2024년 12월 22일

게재 확정일 : 2024년 12월 26일

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 곽윤직·김재형, 『민법총칙』(박영사, 2012).
- 김상용, 『민법총칙』(화산미디어, 2009).
- 김주수, 『민법총칙』(삼영사, 2013).
- 김증한·김학동, 『민법총칙』(박영사, 2013).
- 지원림, 『민법강의』(홍문사, 2020).
- 송덕수, 『신민법강의』(박영사, 2018).
- 이영준, 『민법총칙』(박영사, 2007).
- 편집대표 곽윤직, 『민법주해(III)-총칙』(박영사, 1992).
- 편집대표 양창수, 『민법주해 4』(박영사, 2022).
- 권오상, “민법 제150조 제1항의 조건 성취에 대한 반신의행위 검토 — 대법원 2022. 12. 29. 선고 2022다266645 판결 —”, 『법학연구』(연세대학교 법학연구원, 2023), 제33권 제1호.
- 김민규, “수진기회상실론- 일본의 판례 및 학설 발전으로부터의 시사 -”, 『재산법연구』(한국재산법학회, 2006) 제22권 제3호.
- 김증한, “물권적 기대권론”, 『민사법학』(한국민사법학회, 1978) 제1권.
- 김학동, “소유권유보부매매의 법률관계.” 『민사법학』(한국민사법학회, 2005), 제27권.
- 나지수, “추가연계증권(ELS) 델타헤지거래 관련 분쟁의 분석”, 『증권법연구』(한국증권법학회, 2016), 제17권 제1호.
- 송옥렬, “동반매도요구권과 대주주의 실사협조의무-대법원 2021. 1. 14. 선고2018다223054판결-”, 『BFL』(서울대학교 금융법센터, 2021), 제108권.
- 양삼승, “가정적 인과관계에 대한 고찰(하)”, 『법조』(법조협회, 1980), 제30권 제2호.
- _____, “손해배상과 잠재적·후발적 사정”, 『민사법학』(한국민사법학회, 1982), 제3권.
- 양창수, “민법 제150조의 입법목적과 유추적용”, 『사법』(사법발전재단, 2020), 제1권 제51호.
- 윤진수, “가정적 인과관계 및 후발적 손해확대에 관한 고찰”, 『비교사법』(한국사법학회, 2023), 제30권 제4호.
- _____, “정지조건 성취 방해로 인한 조건성취의 의제여부-대법원 2021. 1. 14. 선고

- 2019다223054판결-”, 『민사법학』(한국민사법학회, 2021), 제96권.
- 이동진, “조건의 성취 방해로 인한 조건의 성취 의제”, 대법원 판례해설 제133호, 법원도서관, 2023.
- 이상훈, “최근 ELS 소송에서의 민법 제150조 제1항 적용의 쟁점과 함의”, 『민사법학』(한국민사법학회, 2016), 제76호.
- 이유진, “동반매도청구권(Drag-Along Right)에 대한 연구 - 대법원 2021. 1. 14. 선고 2018다223054 판결을 중심으로 -”, 『상사판례연구』(한국상사판례학회, 2021), 제34권 제3호.
- 이재우, “불법행위법상 인과관계에 관한 연구”, 연세대학교 박사학위청구논문, 2015.
- 이재웅·김영규, “중개의퇴인의 개업공인증개사 배제에 따른 중개보수청구권에 대한 고찰-일본 판례의 분석을 중심으로-”, 『법학논총』(단국대학교 법학연구소, 2018), 제42권 제2호.
- 이주은, “개정 프랑스민법상 조건부 채무”, 『아주법학』(아주대학교 법학연구소, 2018), 제12권 제3호.
- 이창현, “수익기회의 상실과 손해배상”, 『법학논총』(한양대학교 법학연구소, 2014) 제31권 제1호.
- 임건면, “가정적 인과관계”, 『성균관법학』(성균관대학교 법학연구소, 2004), 제16권 제2호.
- 임현정, “민법상 조건성취 방해 법리에 관한 소고-대법원 2022. 12. 29. 선고 2022다266645 판결을 중심으로-”, 『법학논집』(이화여자대학교 법학연구소, 2023), 제28권 제1호.
- 임현정, “민법상 조건(條件)법리에 관한 연구-민법 제150조를 중심으로-”, 이화여자대학교 박사학위청구논문, 2024.
- 조영일, “물권적 기대권에 관한 고찰”, 조선대학교 석사학위청구논문, 1999.
- 최종길, “물권적 기대권 (1)”, 『사법행정』(한국사법행정학회, 1965) 제6권 제2호.
- 황성일, “등기전부동산매수인의 법적지위에 관한 연구”, 성균관대학교 석사학위청구논문, 2009.

2. 외국문헌

- Forkel Hans, *Grundfragen der Lehre von Privatrechtlichen Anwartschaftsrecht*, Duncker & Humblot, 1962.
- Hermann Fitting, *Über den Begriff der Rückziehung*, Deichert, 1856.
- 石田穰, 『民法總則』, 悠々社, 1992.
- 西宮和夫, 『民法總則』, 弘文堂, 2010.

松岡誠之助, 『ジュリスト』161号, 法律時報, 1958.

葉師寺志光, 『新訂日本民法總論新講』, 明玄書房, 1954.

我妻榮, 『新訂 民法總則(民法講義 I)』, 有斐閣, 1992.

편집대표 於保不二雄, 『新版注釈民法(4) 總則(4)』, 有斐閣, 2015.

Joseph H. King. Jr., "Causation, Variation, and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting Condition and Future Consequence", The Yale Law Journal, 제90권 제6호, 1981.

Joseph H. King. Jr., "Reduction of Likelihood Reformulation and Other Retrofitting of the Loss-of-Chance Doctrine", University of Memphis Law Review, 1998.

3. 전자자료

법제처 국가법령정보센터

<https://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060114#undefined>(최종 방문일 2024. 9. 9.)

대법원 보도자료

<https://www.scourt.go.kr/news/NewsViewAction2.work?pageIndex=1&searchWord=2022%B4%D9266645&searchOption=&seqnum=1328&gubun=702>(최종방문일 2024. 9. 9.)

Abstract

A Brief Consideration of the Scope of Application and Causal Relationship Issues of Article 150 of the Civil Code

Hyeon-jeong LIM*

Article 150 of the Civil Act was not used much in the past, but recently, there are many practitioners and legal scholars who argue for its application. Nevertheless, research by civil law scholars is insufficient, so I believe that there is a need to study this article.

As a result of reviewing the Supreme Court's case law on Article 150 of the Civil Act, our Supreme Court is showing an attitude of deciding whether or not to protect under Article 150 based on the maturity (possibility) of the conditional right, rather than considering it as a subject of application of this article if it is only a 'conditional right'. It can be concluded that this attitude of case law was most directly influenced by Japanese doctrine, and that the background was influenced by the discussions on the right of expectation by German scholars who distinguish between simple expectations and subjective rights of expectation. However, I have doubts about whether this attitude of case law that distinguishes the subject of application of this article is appropriate.

And regarding the requirement of 'causality' in Article 150 of the Civil Act, the current academic conflict of whether or not to fully demand proof of a hypothetical causal relationship of 'would the condition have been fulfilled if there had been no obstruction' has its limitations due to the inherent special nature of 'uncertainty' that conditional rights have. Therefore, I propose that proportional damages can be paid by borrowing the theory of lost opportunity as an alternative.

[Key Words] Article 150 of the Civil Act, Conditions, Obstruction of Condition Achievement, Conditional Right, Hypothetical Causal Relationship

*Judicial Research Officer, Supreme Court of Korea / SJD / Attorney at Law